

1500534-67.2022.8.26.0366

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO RICARDO DE CARVALHO DANTAS

Réu Preso

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra SERGIO RICARDO DE CARVALHO DANTAS imputando-lhe a prática do crime tipificado 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá (SP) - cep 11730-000

1500534-67.2022.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500534-67.2022.8.26.0366

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO RICARDO DE CARVALHO DANTAS

Réu Preso

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra SERGIO RICARDO DE CARVALHO DANTAS imputando-lhe a prática do crime tipificado 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Sustenta a denúncia que, no dia 31 de julho de 2022, por volta das 10h35, na Avenida Marcelino Rodrigues de Meira, próximo ao numeral 1676, Balneário Itaguai, nesta cidade e Comarca de Mongaguá, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 340 pedras de crack, 60 porções de maconha e 530 de cocaína, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e auto de constatação de preliminar de fls. 15/16.

Narra que o acusado, querendo praticar a traficância, trazia consigo as mencionadas substâncias entorpecentes, na localidade conhecida como "Boca da Faixa". Nas condições objetivas de tempo e lugar acima indicados, policiais militares faziam o patrulhamento pelo local, quando notaram que determinado indivíduo, que trazia consigo uma sacola plástica, percebendo a passagem da viatura, passou a correr em

direção oposta ao veículo da Força Pública. Em razão disso, os policiais decidiram pela abordagem. Após breve acompanhamento, a equipe policial deteve referido indivíduo, identificado como SERGIO. Na sacola plástica que o acusado trazia consigo, foram encontradas as supramencionadas drogas, além da quantia de R\$ 142,00 em espécie. A quantidade de drogas, as atitudes do acusado, o local onde se deram os fatos e a apreensão de quantia em dinheiro de procedência não esclarecida, indicam que o inculpado se dedicava ao comércio espúrio de entorpecentes. O laudo foi juntado a fls. 77/79.

A denúncia foi recebida (fls. 52/54) e o réu foi citado (fls. 52/54), apresentou resposta à acusação a fls. 55.

Em audiência foram colhidas as declarações do ofendido e os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório, em que o acusado confessa a prática delitiva.

Em alegações finais, o Ministério Público pugna pelo acolhimento da pretensão acusatória, com valoração na fixação da pena da quantidade e diversidade das drogas, da agravante da reincidência e da atenuante da confissão, com afastamento da figura privilegiada diante da reincidência, com regime inicial fechado. E a defesa técnica, a absolvição do acusado, ante a falta de provas da traficância ou de seu destino a terceiros, sucessivamente pela consideração da confissão e fixação da pena no mínimo.

Folha de antecedentes e certidão de distribuição estão a fls. 39/41 e fls. 42/44. Fundamentação

Existência e Autoria

A existência e a autoria delitivas restaram demonstradas pelas provas pericial, documental e oral produzidas.

As declarações dos policiais em juízo confirmam a apreensão de substâncias nos termos do auto de apreensão, em que o perito oficial detectou a presença de tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína, assim de 340 porções individuais de crack, 60 de maconha e 530 de cocaína, com massa líquida de 68,5g, 173,3g e 143g.

A própria variedade e quantidade de droga apreendida, bem superior ao que normalmente se destinaria ao consumo próprio de um usuário da droga, corrobora a versão acusatória no sentido de que seu destino não era o consumo pessoal, mas a entrega a terceiros.

Nos moldes do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Para apreciação do vetor objetivo da natureza e quantidade da droga adota-se como parâmetro um consumo diário individual médio de até 2,5g de maconha (cerca de 2 a 4 cigarros), de até 16 pedras de crack (cerca de 5,2g) e de até 0,2g de cocaína, conforme a Portaria 94/1996 dos Ministérios da Justiça e da Saúde de Portugal, sugerida por Maria Tereza Uille Gomes, então Secretária de Estado da Justiça Cidadania e Direitos Humanos do Paraná (Estudo Técnico para Sistematização de Dados sobre Informações do Requisito Objetivo da Lei nº 11.343/2006, 2014).

Tal quantidade é compatível com o uso semanal médio de 14 cigarros de maconha referido em pesquisa com 80 dependentes da maconha do ambulatório do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas da Faculdade de Medicina da USP (Hercilio Pereira de Oliveira Junior, Avaliação do perfil de comorbidades, gravidade da dependência e motivação para o tratamento em uma amostra de usuários de maconha que procuram tratamento, Mestrado, USP, 2010); e com o uso de até 2g por episódio relatado por 58% de 86 usuários de maconha atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010).

Quanto ao crack, tal quantidade de consumo individual acima referido é compatível com o padrão médio de uso no Brasil de 13,42 porções por dia apurado por pesquisa da FIOCRUZ, idealizada em conjunto com a Secretaria Nacional de Políticas sobre

Drogas (Pesquisa Nacional sobre o Uso do Crack, 2014); com o uso de mais de 10 pedras por episódio relatado por 47% de 67 usuários de crack atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010); com o relato de uso de 10 ou mais pedras por 69,5% de 67 usuários de crack atendidos nos Centros de Atenção Psicossocial de Igrejinha, Taquara e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul (Rogério Lessa Horta et al, Perfil dos usuários de crack que buscam atendimento em Centros de Atenção Psicossocial. Cad. Saúde Pública, v. 27, n. 11, p. 2263-2270, 2011); e com a média de 73,2 pedras de crack por semana encontrada em pesquisa com 72 pacientes do Centro de Atenção Psicossocial de Serra, no Espírito Santo (Janine Andrade Moscon, Avaliação dos padrões de consumo de crack, cognição global e de funções executivas em usuários de ambulatório especializado de alta demanda, Mestrado, UFES, 2013).

Quanto à cocaína, tal quantidade de consumo individual acima referido é compatível com o uso de 2g de cocaína por mês um dos vetores para a definição de dependência em pesquisa estadunidense que apurou, ainda, consumo médio mensal de 0,8g de cocaína entre todas as 2.349 pessoas que disseram ter consumido a droga entre 1991 e 1993 (Kevin Chen e Denise Kandel, Relationship between extent of cocaine use and dependence among adolescents and adults in the United States, Drug and Alcohol Dependence, v. 68, 2002), mas é subestimada frente ao uso de até 2g a 5g por episódio relatado por 47% de 87 usuários de cocaína atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010), de modo que aquele valor não deve ser tomado de modo absoluto e deve ser sopesado, por exemplo, com o grau de pureza da droga – ainda assim, no caso, a quantidade é realmente expressiva e desborda do consumo pessoal.

E a autoria delitiva também restou comprovada pelos elementos probatórios colhidos, somando-se à confissão judicial do acusado (artigo 197 do Código de Processo Penal).

Com efeito, o policial militar Adriano disse que estava em patrulhamento de rotina, passando pelo local de conhecido ponto de venda de drogas, quando flagraram SERGIO no tráfico da droga, com ele encontraram a droga. Quando visualizou a viatura, SERGIO saiu correndo e tentou empreender fuga. Lograram ver que ele tinha uma pochete no peito e um saquinho contendo a droga na outra mão. Tinha pouco dinheiro com ele. Era uma quantidade considerável de droga com ele, talvez 300 pinos de cocaína. Não conhecia o acusado e não visualizaram atos de comércio. Informalmente, SERGIO confessou que trabalhava no ponto de venda. Apenas sua viatura, com mais dois policiais, participou da abordagem.

O policial militar Alberto disse que estava em patrulhamento por área de tráfico de drogas (Rua Marcelino de Meira Rodrigues, Boca da Faixa) e SERGIO estava vindo a pé, com uma sacola na mão e uma bolsa cruzada a tira-colo. Desembarcou para efetuar a abordagem e SERGIO saiu correndo, mas lograram detê-lo com a sacola e a bolsa cheia de droga. Tinha dinheiro e drogas com SERGIO. Não se lembra se tinha anotações do tráfico.

Enfim, nestes termos, restaram confirmadas as teses de fato da acusação e “não há elementos de prova que tornem viável ter ocorrido fato concreto diverso de qualquer proposição fática que integre a imputação.” (Gustavo Badaró, Epistemologia Judiciária e Prova Penal, RT, 2019, p. 259).

Adequação Típica

Prevista na lei penal, a conduta do acusado também é materialmente típica, pois causa expressiva lesão, ainda que potencial, ao bem jurídico penalmente protegido. Por consequência, a severa intervenção penal não viola o direito constitucional à liberdade, atendido o postulado da proporcionalidade.

Uma vez que o acusado é reincidente, é inaplicável a causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06.

Ilícitude e Culpabilidade

Presente a tipicidade, não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que a

conduta tenha sido praticada em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou em exercício regular de direito, o que excluiria a ilicitude da conduta, de acordo com o artigo 23 do Código Penal. À época dos fatos, o réu era maior de 18 anos, atendido o critério constitucional de imputabilidade (artigo 228 da Constituição Federal); e era plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, sem que haja elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que não tivesse plena saúde mental, estivesse fortuitamente embriagado ou sob o efeito de substância psicoativa ou, ainda, sob dependência de droga (artigos 26 e 28 do Código Penal e do artigo 45 da Lei 11.343/2006).

Por fim, culturalmente inserido na sociedade brasileira, o réu tinha ao menos potencial consciência da ilicitude e não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que lhe fosse inexigível conduta diversa, por estar sob coação irresistível ou agir em estrita obediência a ordem (artigo 22 do Código Penal).

Dosimetria

Passo à individualização da sanção penal exigida pelo artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, no procedimento trifásico do artigo 68, caput, do Código Penal, na medida em que necessária e suficiente à retribuição e à prevenção especial.

Na primeira etapa (artigo 59, incisos I e II, do Código Penal), aprecio as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis a partir da pena média, a fim de atender o princípio da isonomia do artigo 5º, caput, da Constituição Federal, pois “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador. Esse é um ponto estratégico na individualização da pena, justamente para evitar a nociva padronização. A quem merece pena superior ao mínimo, deve o juiz saber aplicá-la, por uma questão de justiça.” (Guilherme de Souza Nucci, Curso de Direito Penal, v. 1, 3ª ed., 2019, Cap. XXXII, item 3.1, p. 1020). Do contrário, dar-se-ia idêntico tratamento para condutas de distinta reprovabilidade quando presentes exclusivamente circunstâncias judiciais favoráveis.

O nível de consciência do injusto e o grau de exigibilidade de comportamento diverso (cf. Juarez Cirino dos Santos, Direito Penal – Parte Geral, 5ª ed., 2012, p. 518-519) não destoam da culpabilidade já pressuposta na caracterização do crime. O acusado não ostenta Maus antecedentes, inexistindo condenação criminal transitada em julgado a ser valorada nesta fase, conforme exige a presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), nos moldes da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e da tese com repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 591054, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014).

Nada de desfavorável se comprovou a respeito da conduta social do acusado, o que, de qualquer modo, só justificaria sanção penal mais gravosa em função da prevenção especial positiva, prejudicada ante o “quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas” no sistema penitenciário brasileiro (STF, ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015). Não tendo o titular da ação penal, neste ponto, se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, de rigor considerar favorável a conduta social do acusado, em atenção ao in dubio pro reo (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Não há elemento probatório seguro a respeito da personalidade do acusado, o que é questão técnica complexa e de, no mínimo, duvidosa convencionalidade (v. Corte Interamericana de Direitos Humanos, *Fermín Ramírez vs. Guatemala*, julgado em 20/06/2005).

Os motivos e as circunstâncias do crime não destoam do que é acobertado pelo tipo penal e não justificam imposição de sanção mais branda ou mais severa.

As consequências do crime são igualmente neutras, nesta fase, diante da extensão relevante, mas não excessiva, de atingimento ao bem jurídico tutelado.

A natureza e a quantidade da droga são importantes e não autorizam um juízo

favorável ao acusado, pois superiores ao suprimento mensal de um usuário de droga, nos termos já adotados, mas não são expressivas a ponto de justificar a elevação da pena-base.

Por tudo isto, considero favoráveis a conduta social e neutras as demais circunstâncias. Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, atribuo peso equivalente a 1/5 para as circunstâncias relativas à natureza e a quantidade da droga, à personalidade e à conduta social do agente e 1/6 para as demais, tudo sobre o intervalo de pena em abstrato a cada circunstância favorável e desfavorável. A fração é eleita em interpretação sistemática da fração mínima das causas de aumento e diminuição expressas no Código Penal, aplicando-se sobre o intervalo em respeito ao papel do legislador na individualização da pena, de modo que possa alcançar, em tese, o piso ou o teto legais.

Fixo a pena-base em 8 anos de reclusão.

Na segunda etapa (artigos 61 a 67 do Código Penal), é de rigor a atenuação da pena em razão da confissão (artigo 65, inciso III, 'd', do Código Penal), ainda que parcial ou qualificada (cf. STJ, AgRg no AREsp 1763911/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021; AgRg no AREsp 1754440/MT, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021), pois prepondera, aqui, a colaboração com a apuração criminal e a certeza do julgamento em detrimento do arrependimento e penitência pelo crime. Por conseguinte, atenuo a pena em 1/6 sobre o intervalo de pena em abstrato, que é reduzida para 6 anos e 4 meses.

Deixo de valorar negativamente a reincidência, pois já serviu de critério para o afastamento da causa de diminuição na terceira etapa, evitando-se o bis in idem. Nada a alterar na terceira etapa.

Quanto à pena pecuniária, a gradação do número de dias-multa deve observar rigorosamente o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal, conforme tudo o que já se expôs.

Assim, fixo a pena de multa final em 634 dias-multa.

Ausentes elementos sobre a condição econômica dos réus, fixo o valor do dia-multa, nos moldes do art. 43 da Lei 11.343/06, em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Regime inicial

Deixo de promover a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, remetendo a questão ao juízo da execução. Com efeito, o preceito incluído pela Lei 12.736/12 confunde os institutos diversos da fixação do regime inicial e da progressão de regime e, deste modo, viola a Constituição Federal, que consagra a individualização da pena e a isonomia (artigo 5º, caput e incisos I e XLVI).

Já não fosse a previsão do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, também em razão da condenação a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos e da reincidência, fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'b', do Código Penal.

Substituição e sursis

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da quantidade de pena aplicada por crime doloso, não preenchido o requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal, e por se tratar de réu reincidente no mesmo crime doloso, nos moldes do artigo 44, inciso II e parágrafo 3º, do Código Penal, mesmos motivos pelos quais não cabe a suspensão condicional da pena, assim independentemente da idade do acusado ou de razões de saúde (artigo 77, caput e parágrafo 2º, do Código Penal).

Efeitos secundários da condenação

Decreto a perda dos instrumentos do crime, diante de sua ilicitude (art. 91, II, 'a', do CP), e dos bens e valores auferidos com a prática criminosa (art. 91, II, 'b', do CP), ressalvado o direito de terceiro de boa-fé.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar SERGIO RICARDO DE CARVALHO DANTAS à pena de reclusão de 6 anos e 4 meses, em regime inicial fechado, e a 634 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo,

pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Prisão preventiva

Nos termos do artigo 387, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, aprecio e mantenho a prisão preventiva. Mantida a prisão durante a instrução criminal, porque presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível à preservação da ordem pública e à aplicação da lei penal, e ora confirmada, com a condenação, a imputação por crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tais requisitos subsistema de forma ainda mais nítida.

Assim, recomendo o acusado à prisão. Expeça-se a guia de recolhimento provisória (artigo 8º da Resolução CNJ 113/2010).

Custas

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 4º, parágrafo 9º, alínea 'a', da Lei Estadual 11.608/03). A gratuidade é questão a ser apreciada em momento oportuno, pelo juízo da execução, se o caso.

Providências Finais

Não havendo interesse em sua conservação (art. 124 do CPP), encaminhem-se os instrumentos do crime para sua inutilização após o trânsito em julgado.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão, se o caso, e a guia de recolhimento definitiva, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Penal e da Resolução CNJ 113/2010; comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; e comunique-se ao Instituto de Identificação Civil (artigo 709 do Código de Processo Penal).

Ainda com o trânsito em julgado, determino a destruição das amostras da droga guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, comunicando-se à autoridade policial.

Também após o trânsito em julgado, atualize-se o histórico das partes no cadastro processual com a respectiva anotação; expeça-se a certidão de honorários ao advogado dativo, se o caso; expeça-se a competente certidão para execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa).

Comunicado o ajuizamento da execução da multa (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou verificada a prescrição da pretensão executória (evento 22), arquivem-se os autos com a movimentação 61619 no SAJ.

Int.

Mongaguá, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA